

1500250-59.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... absorvido pelo crime de roubo, homicídio ou tráfico de drogas praticado no mesmo contexto fático, com subordinação e dependências das condutas (STJ, HC 325.387/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 1116928/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018; AgRg no AREsp n. 2.014.637/ES, Rel. Min. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500250-59.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500250-59.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra NORIVAL DOS SANTOS NETO imputando-lhe a prática dos crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, na forma consumada, com a pretensa incidência das causas de aumento dos parágrafos 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo, por duas vezes, em concurso formal do artigo 70 do Código Penal, bem assim do crime tipificado no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Sustenta a denúncia que, em data incerta, mas certamente no ano de 2014, em local também incerto, o acusado adquiriu uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, com numeração raspada, e 12 munições de mesmo calibre.

Sustenta também que, no dia 10 de maio de 2022, por volta das 14h55, na Avenida São Paulo, nº 2114, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos itens informáticos e eletroeletrônicos, dentro os quais 24 aparelhos celulares, um tablet e uma serra elétrica, pertencentes à Lojas Americanas, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 39/40 e um aparelho celular da marca Samsung, pertencente à vítima Lucas, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 41.

Narra que o acusado, no ano de 2014, adquiriu a arma de fogo e munições acima descritas, por ela pagando o valor de R\$ 600,00, para a prática de crimes (vide processo 0008793-30.2015.8.26.0477, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Praia Grande, cf. certidão de fls. 51/53). Na data dos fatos, o acusado, querendo

praticar a subtração, se dirigiu ao estabelecimento-vítima a bordo de uma motocicleta, conduzida por seu comparsa, que ficou no lado de fora do estabelecimento, pronto para juntos se evadirem do local. Ao aproximar-se do balcão, rendeu a funcionária Talita, e mostrando a arma, anunciou o assalto. Em contínuo, perguntou pelo local em que estavam os celulares. Diante da ameaça, a vítima levou o acusado até o escritório onde os celulares eram guardados em cofre. No trajeto, o segurança Lucas também foi rendido pelo acusado e teve seu aparelho celular subtraído. As vítimas abriram o cofre, e a mando do criminoso, colocaram os aparelhos em uma sacola, que foi levada para a parte externa da loja. Neste mesmo momento, o acusado obrigou que os ofendidos entregassem as chaves do quintal do estabelecimento. Ocorre que, após isso, os funcionários conseguiram ir para a frente da loja, onde acionaram uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local. Durante a abordagem, o acusado foi encontrado na posse da arma de fogo e do aparelho celular de propriedade da vítima Lucas.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva a fls. 61/63.

A denúncia foi recebida (fls. 61/63) e o réu foi citado (fls. 61/63), apresentou resposta à acusação a fls. 83/85.

Em audiência foram colhidas as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado confessa a prática do crime, motivado pela necessidade de quitar uma dívida de sua mãe com agiota, confirmando ter agido com um amigo que o levou de moto, emprestou a arma, naquele mesmo dia, e esperou do lado de fora, dizendo que agiu de forma comedida e sem agredir ninguém. Perguntado sobre o interrogatório na fase policial, em que constou ter adquirido a arma em 2014, disse ter mentido.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, ressaltando a prova oral quanto ao crime de roubo, em concurso de agentes, inclusive com a sua consumação ante a inversão da posse dos bens, e, quanto ao crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, a confissão na fase policial e a condenação por outro crime de roubo contemporâneo com emprego de arma de fogo, com valoração na fixação da pena da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, as duas majorantes e o concurso formal diante das duas vítimas do crime de roubo, com regime inicial fechado. E a defesa técnica, a desclassificação do crime de roubo para a figura tentada, porque não havida inversão da posse dos celulares, e o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, não identificado o segundo indivíduo, e do emprego de arma, ausente laudo, com a fixação da pena no mínimo e consideração da confissão; bem assim a absolvição quanto ao crime de posse de arma de fogo, sendo insuficiente a confissão na fase inquisitiva e não confirmada em juízo.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 47/50 e fls. 51/53.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria da ação criminosa restaram parcialmente demonstradas pelas provas documental e oral produzidas.

A vítima e as testemunhas policiais ouvidas em juízo confirmaram que o acusado ingressou no estabelecimento comercial e, em parceria com segundo indivíduo não identificado, utilizando-se de arma de fogo, obrigou aos funcionários que retirassem os aparelhos celulares do cofre e os colocassem em um saco e ao funcionário Lucas que entregasse seu próprio aparelho celular, sendo interrompida a empreitada criminosa pela chegada dos policiais quando NORIVAL tentava abrir a porta dos fundos para por ela se evadir do local.

Com efeito, a vítima Lucas disse que estava na cozinha da loja no dia dos fatos e achou estranha a movimentação da loja e foi até os fundos para ver o indivíduo conversando com uma mocinha. Na sequência, NORIVAL abordou o depoente, sua colega de trabalho Talita e duas clientes. Ele pediu para que abrisse o cofre e liberasse o celular. Só conseguiu visualizar NORIVAL, mesmo pelas câmeras de monitoramento. NORIVAL estava armado e, quando do ingresso na cozinha, apontou a arma e anunciou o assalto, mandando que abrisse o cofre e dizendo "se não abrir, já sabe...". Apontou a arma antes, na cozinha, e, depois, ficou olhando, no corredor, colocarem as coisas subtraídas no saco de lixo. Foram subtraídos dois celulares de funcionários

e trinta celulares da loja. O seu celular foi pego, colocado no bolso de NORIVAL, mas o bem foi recuperado logo após, com a sua prisão em flagrante. Dois celulares de funcionários não foram recuperados. Após, NORIVAL quis deixar o saco com os celulares na doca, para que saísse por trás, dirigindo-se à frente da loja para pegar as chaves das docas, momento em que a polícia chegou e o deteve. Ficou sabendo pelas moças que estavam no caixa que um segundo rapaz as abordou lá embaixo, pedindo os celulares. O segundo indivíduo não chegou a subir. NORIVAL queria que Talita levasse o saco com os celulares, mas o depoente se prontificou a levar porque ela estava muito nervosa. Com a chegada da polícia, o saco estava nos fundos da loja e não nas mãos de NORIVAL. Não viu o segundo rapaz correr, que, vendo a movimentação, já tinha saído correndo. Todos os objetos foram recuperados, com exceção dos dois celulares das funcionárias de baixo. NORIVAL apresentou uma arma prateada, “quadradona”, com 8 ou 12 balas no pente, quando o policial a manipulou.

O policial militar Rodrigo disse que estava em patrulhamento pelo bairro quando o COPOM irradiou roubo em andamento com dois indivíduos, um de camisa verde fora do comércio e outro dentro do estabelecimento. Chegando ao local, não viram o indivíduo de verde, mas, adentrando, NORIVAL estava lá, com o segurança e o gerente, vindo de trás da loja. Identificando-se como policial, NORIVAL colocou as mãos para cima e disse “perdi, perdi”, sendo preso e conduzido à Delegacia de Polícia. A informação do segundo indivíduo veio do COPOM e foi confirmado pelas vítimas no local. Com NORIVAL, em seu bolso, foi encontrado o aparelho celular do segurança e os celulares da loja estavam separados próximos ao portão de saída – no momento da abordagem ele queria a chave acho que do cofre para pegar mais celulares. Não chegou a ver outras pessoas se evadindo do local. Teve outros celulares subtraídos, mas não se recorda dos detalhes, provavelmente tendo sido levado embora pelo segundo indivíduo. Duas vítimas foram conduzidas à Delegacia, a gerente e o segurança. Não recorda se outros indivíduos reclamaram de pertences subtraídos.

O policial militar Bruno disse que no dia dos fatos foi irradiado via COPOM um roubo em andamento nas Lojas Americanas. A sua equipe, em patrulhamento no bairro Agenor de Campos, foi até o local, tendo poucas informações. Chegando ao lado, os funcionários, nervosos, indicaram que havia um roubo dentro da loja. Adentraram na loja e NORIVAL estava em posse de uma arma de fogo e utilizava como escudo humano Lucas e outra funcionária. Foi dada voz de prisão, ele pôs a arma no chão e se deitou, sendo, então, preso. Perguntado, disse que recebeu informação de dois indivíduos roubando a loja, passadas as características da vestimenta de NORIVAL e que eles estariam de moto. No local só conseguiram prender NORIVAL e, informalmente, ele mesmo disse que o parceiro havia se evadido. Não visualizaram o segundo indivíduo de que falaram os funcionários. Os celulares estavam separados e deixados na porta, próximo da escada, e NORIVAL estava com um celular da funcionária em sua posse – os demais estavam preparados para serem levados, numa sacola.

Tudo o que se soma à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Contudo, não se crê tenha sido suficientemente demonstrada a aquisição pelo acusado, a qualquer tempo, da arma de fogo apreendida. O único elemento neste sentido foi o teor do interrogatório na fase policial. Ainda que se o admita, inclusive porque pouco crível a tese apresentada no interrogatório judicial sobre a divergência nas versões, não há qualquer outro elemento probatório a corroborar esta confissão, conforme exige o preceito já citado do artigo 197 do Código de Processo Penal.

De se notar que a imputação inicial é da conduta de adquirir a arma em 2014. A propósito, de um lado, a condenação por outro crime de roubo com emprego de arma de fogo, em junho de 2015 (0008793-30.2015.8.26.0477), é insuficiente a indicar sequer

que o acusado já tivesse em seu poder a arma de fogo, mormente porque, conforme se depreende da sentença condenatória daquele feito, os artefatos lá utilizados aparentemente foram apreendidos na ocasião. E, de outro, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem se sedimentando no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de roubo, homicídio ou tráfico de drogas praticado no mesmo contexto fático, com subordinação e dependências das condutas (STJ, HC 325.387/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 1116928/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018; AgRg no AREsp n. 2.014.637/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022; AgRg no HC n. 684.750/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), como no caso. Enfim, a este respeito, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto a este aspecto da responsabilidade penal do acusado. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se o afastamento da pretensão nesta particular.

Adequação Típica

Como se disse, o quadro probatório evidenciou que o acusado praticou, de forma consciente e deliberada, a conduta de tentar subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça, nos exatos termos do artigo 157, caput, do Código Penal, não logrando consumir o delito por circunstância alheia à sua vontade.

A propósito, é certo não se exigir que o agente obtenha a posse mansa, tranquila e desvigiada da coisa, transportando-a para outro lugar, para que se consuma a condute nuclear de subtração. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo: “consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). No mesmo sentido é a Súmula 582 daquela Corte Superior: “Consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”.

Isto não significa, porém, que o delito esteja consumado tão somente a partir da retirada dos celulares do cofre ou da entrega dos aparelhos ao agente se ele não logra nem mesmo sair do estabelecimento, sendo surpreendido por policiais militares ainda no interior da loja. Em tal situação, de rigor reconhecer a tentativa, apenas. Confira-se, a propósito, o que já decidiu o Tribunal de Justiça em casos de todo semelhantes:

“Não houve consumação dos delitos. Não se pode falar que os recorrentes detiveram a posse de fato dos objetos da subtração, pois foram surpreendidos pelos policiais militares antes que tivessem a oportunidade de deixar o local dos fatos. Inexistiu, dessa forma, a inversão da posse, o que permite o reconhecimento da tentativa.” (Apelação 1502437-17.2019.8.26.0537, Rel. Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 14/07/2021)

“Apelação da Justiça Pública – Reconhecimento da modalidade consumada do roubo – Impossibilidade – Prisão em flagrante ainda no interior do estabelecimento comercial – Inocorrência da inversão da posse dos bens que pretendiam roubar – Recurso desprovido.” (Apelação 1503611-98.2018.8.26.0536, Rel. Cesar Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 26/07/2019)

“RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – VIABILIDADE – Os apelantes foram presos ainda no interior do estabelecimento comercial da vítima, vez que policiais militares em patrulhamento de rotina, ao serem noticiados do ocorrido, conseguiram deter os réus quando estavam prestes a fugir, havendo, portanto, a interrupção do iter criminis por circunstâncias alheias às suas vontades.” (Apelação 0048381-30.2016.8.26.0050,

Rel. Paulo Rossi, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 21/09/2018)

Diante da prova oral produzida, aliada à confissão, de rigor o reconhecimento da causa de aumento do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, deflui do artigo 175 do Código de Processo Penal a exigência de demonstração pericial quanto à natureza e eficiência do instrumento utilizado no crime, isto é, quanto à aptidão da arma para realizar disparos, mormente porque a finalidade da causa de aumento é a maior reprovação da conduta que expõe a integridade física e a vida da vítima a maior risco - e, por isto, o emprego de simulacro de arma de fogo não caracteriza a majorante conforme entendimento sedimentado desde o cancelamento da Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda assim, vale a mesma regra do artigo 167 do Código de Processo Penal, podendo ser suprida a impossibilidade de exame do instrumento por outras provas de sua aptidão, como o depoimento das vítimas ou testemunhas que presenciaram a violência ou grave ameaça exercida com o emprego do artefato. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento segundo o qual "I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria." (EResp 961.863/RS, Relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011). Mais recentemente: ERESp n. 1.111.500/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe de 30/5/2011; AgRg nos EAREsp n. 443.045/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 8/10/2014, DJe de 14/10/2014. Como se extrai do voto condutor daqueles primeiros Embargos de Divergência: "Salvo melhor juízo, arma significa no senso comum instrumento capaz de produzir em outra pessoa ou animal resultado que iniba ou elimine a ação ou reação respectiva. Assim, quando a lei refere o uso de arma no tipo legal como qualificadora do crime de roubo assenta indubitavelmente ser o uso de instrumento capaz de produzir lesão ou dano cuja ameaça assim se valoriza penalmente. Talvez por essa razão o Supremo Tribunal Federal, ainda em maioria, decidiu que a arma tem potencial lesivo por si só, ou in re ipsa, o que de resto parece mais consentâneo com o texto legal, com a realidade e com a interpretação mais próxima dos costumes e valores praticados pela sociedade atual. [...] Nesse quadro, a exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. A divergência que se estabelece portanto acerca do conceito de arma nos moldes mencionados deve ser resolvida pela prevalência da tese de que arma é em si efetivamente capaz de produzir dano ou lesão. A eventual hipótese de não se constituir a arma de instrumento de potencial lesivo deve ser demonstrada pelo agente: assim, na arma de brinquedo, na arma defeituosa ou na arma incapaz de produzir a lesão ameaçada. Essa inversão do ônus da prova, ademais, se reveste de racionalidade evidente pois é o agente que, de posse dela, poderá mais facilmente produzir tal prova.".

No caso, a prova oral revelou que o acusado se utilizou de um artefato ao menos assemelhado a uma arma de fogo, mas sem que tenha havido efetivo disparo. O objeto foi apreendido e a autoridade policial o identificou como um revólver Taurus, com

12 projéteis em seu interior, mas sem que tenha sido realizado o competente exame para confirmar a impressão da autoridade policial quanto a sua natureza e constatar a aptidão para realizar os disparos. E o Ministério Público, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada requereu.

Neste contexto, à míngua do competente exame pericial na arma que foi efetivamente apreendida quando da prisão em flagrante e de qualquer outro elemento probatórios da aptidão do artefato para realizar disparos, impõe-se o afastamento da majorante. De todo pertinente, no ponto, o voto-vencido do Des. Celso Limongi, então convocado no Superior Tribunal de Justiça: "É verdade, a presunção é a de que a lesividade da arma está nela mesma, desde que esteja apta a disparar, e isso é matéria de prova, a demandar o que se exige na 6ª Turma, a saber, a apreensão e perícia da arma. A Deontologia Jurídica [do Direito] exige compromisso com a Justiça. Esse compromisso não admite que, para se fazer Justiça, se faça injustiça. Antes um culpado solto que um inocente preso. Daí a possibilidade de se requerer revisão criminal. O motivo é óbvio: um erro não justifica outro, todos concordamos. É possível, como anota o Ministério Público Federal, que um agente, para subtrair a coisa, tenha feito uso de arma de fogo apta a disparar e, mesmo assim, à falta de prova dessa aptidão, deixe de ser condenado nesta medida. Neste caso, não se terá feito Justiça, pois a pena seria menor do que aquela que corresponderia à conduta, aspecto que, por certo, desagradará a acusação, sempre zelosa de seu munus. Mas o inverso é também possível, ou seja, alguém que faça uso de uma arma de brinquedo, ou defeituosa, ou até mesmo de um simulacro de arma, seja, por presunção de sua funcionalidade, condenado por roubo agravado pelo emprego de arma de fogo, e, aí, fez-se injustiça, porquanto a pena será maior do que a devida. Esta é a diferença de situações que nos cumpre discernir. O juízo penal condenatório não pode advir de presunção. Nem mesmo a Lei das Armas presume a funcionalidade de toda e qualquer arma de fogo. É por isso que o Direito Penal consagra o in dubio pro reo. A única presunção admitida pela Constituição, em tema penal, é iuris tantum de não culpabilidade. O resto é matéria de prova. Daí a necessidade de apreensão e perícia da arma, ainda que branca. Há sempre a possibilidade de ser uma faca sem ponta ou gume, um pedaço de cabo de vassoura ou um canivete sem lâmina, como já previu o Ministro Nilson Naves, no HC-70.544: "Ora, arma sem eficácia não é arma, seria como um canivete ao qual faltassem a lâmina movediça e o cabo. As coisas são o que são, sob pena de abstração da sua realidade. Quando vagamos, a realidade não nos acompanha, e isso não é bom para a dogmática penal". Dessarte, se não se tem prova da funcionalidade da arma de fogo, como é o caso de que ora tratamos, não é possível reconhecer a causa especial de aumento correspondente. É claro que, se ficar provado, no caso concreto, mesmo que por outros meios, que a arma estava apta a produzir os efeitos que dela se pode esperar – efeito que, no caso de arma de fogo, é o disparo de projéteis –, ter-se-á configurada a causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Cód. Penal. Como já afirmei antes, (HC-152.297, DJe de 21.6.10), e agora reafirmo, "A ausência de apreensão e de perícia da arma, nos casos em que não houve disparo, impossibilita a comprovação que poderia lesionar mais severamente o bem jurídico tutelado, caso em que se configura o crime de roubo, por inegável existência de ameaça, sem, contudo, justificar a incidência da causa de aumento." (EREsp 961.863/RS, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011).

No mais, prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Incide, ainda, a agravante da reincidência, nos termos dos artigos 61, inciso I, e 63 do Código Penal, cuja constitucionalidade já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (RE 453000, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013).

Com efeito, o acusado já havia sido condenado, com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao caso vertente, nos autos nº 0008793-30.2015.8.26.047, crime do art. 157, §2º, I e II, em 05/06/2015, com trânsito em 14/02/2018.

Constata-se, ainda, a subtração do patrimônio de duas vítimas distintas, do

estabelecimento comercial e de seu empregado, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação, contra duas vítimas distintas, sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), nos exatos termos da imputação.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As circunstâncias, porém, ensejam maior reprovação diante do emprego ao menos de um simulacro de arma de fogo, apto a causar grave ameaça mais severa, reduzindo a possibilidade de reação ou defesa da vítima e provocando maior abalo psicológico, bem assim do tempo de duração da ação criminosa, subjugadas as vítimas, forçadas a abrir o cofre do estabelecimento e a recolher os objetos do crime sob a mira do artefato.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

O comportamento da vítima não contribuiu para o delito, cuja censurabilidade não é por isto diminuída.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social, desfavoráveis as circunstâncias do crime e neutras as demais circunstâncias. Não havendo motivo para atribuição de sobrevalor a nenhuma delas, atribuo a cada circunstância favorável e desfavorável peso equivalente a 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 7 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal) e seu agravamento por força da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), cuja constitucionalidade já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (RE 453000, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013). Note-se que, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo (EREsp 1154752/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/05/2012, DJe 04/09/2012; REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), compensam-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Na terceira etapa, elevo a pena de 1/3 de acordo com o artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, no mínimo diante do curso de apenas um outro agente. Ainda, reduzo a pena de 1/3 de acordo com o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, conforme o grau de proximidade da consumação (v. Guilherme Nucci, Código Penal Comentado, 2017, art. 14, item 36), no caso tendo o agente recolhido todos os pertences em uma sacola e estando prestes a deixar o estabelecimento, pouco faltando para inverter a posse e consumir o delito.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 6 anos, 2 meses e 20 dias.

Por fim, nos termos do artigo 70 do Código Penal, atingido o bem jurídico de duas vítimas distintas, aplica-se uma única vez a pena, aumentada de 1/6, totalizando 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs, apenas com a ressalva de que o intervalo do artigo 49 do Código Penal, de 10 a 360 dias-multa, deve ser proporcional, pelo imperativo constitucional da isonomia, à natureza e à gravidade do delito (v. Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, v. 1, Saraiva, 2009, p. 613). Para tanto, adota-se como teto da primeira fase valor proporcional à pena máxima cominada para o delito em comparação com o máximo de 30 anos cominado pelo Código Penal.

Assim, correspondendo a pena de multa máxima proporcional a 126 dias-multa e a pena-base a 68 dias-multa, fixo a pena de multa final em 60 dias-multa, no total de 120 dias-multa pelos dois crimes, lembrando-se que as penas dos crimes em concurso, de qualquer espécie, são somadas (artigo 72 do Código Penal).

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 49, § 1º, do CP, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de

Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e da reincidência, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal, e por se tratar de réu reincidente no mesmo crime doloso, nos moldes do artigo 44, inciso II e parágrafo 3º, do Código Penal, mesmos motivos pelos quais não cabe a suspensão condicional da pena, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Indenização mínima

Deixo de fixar a indenização mínima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) à míngua de pedido do Ministério Público ou da vítima, em homenagem ao princípio do contraditório.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar NORIVAL DOS SANTOS NETO à pena de reclusão de 7 anos, 3 meses e 3 dias, em regime inicial fechado, e a 120 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal, na forma tentada (artigo 14, inciso II), com a causa de aumento do parágrafo 2º, inciso II, do mesmo dispositivo, por duas vezes, em concurso formal do artigo 70 do Código Penal; e o ABSOLVO da imputação da prática do crime do artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e mantenho a prisão preventiva. Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tais requisitos subsistem de forma ainda mais nítida.

Assim, recomendo o acusado à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (artigo 8º da Resolução CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Comunique-se à vítima (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

Caso ainda não cumprido o artigo 1º, caput, da Resolução CNJ 134/11, encaminhe-se a arma de fogo/munição ao Comando do Exército, para destruição ou doação, nos moldes do art. 25 da Lei 10.826/03.

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA